DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2014.01.022

WTO 法专栏

国际投资协定一般例外条款研究*

——与 WTO 共同但有区别的司法经验

梁丹妮**

内容提要:近年来,以条约为基础的投资仲裁案件不断涌现,过分倾向于投资者保护的国际投资仲裁制度饱受批评,发达国家积极推进国际投资协定制度改革,包括增加新条款以重新平衡外国投资者与东道国间权利义务。本文探讨国际投资协定是否有必要增设一般例外条款,如 GATT 第 20 条,允许东道国为实现保护如人类、动植物生命或健康等目标而豁免投资保护义务,以确保国际投资协定与国家公共政策之间的一致性。

主题词:国际投资协定 WTO 一般例外条款 规制性征收

投资自由化和投资促进仍是晚近投资政策的主导内容,不过由于国际经济形势动荡,过去几年内限制性投资措施和行政程序有所增加,投资保护主义风险亦有所抬头,以致投资争议频发。截止 2012 年底全球共有近 3196 项国际投资协定,①以条约为基础的投资仲裁案件不断涌现,其庞大和复杂程度令投资者和东道国都疲于应付。过分倾向于投资者保护的国际投资仲裁制度饱受批评,成为正处在十字路口的国际投资条约制度改革的焦点问题。从国际投资争端本身而言,外国投资者诉东道国的案件已超过 514 起,共有 95 个国家成为被告一方。② 国际投资最为活跃的发达国家积极推进国际投资协定制度改革,如增加新条款,包括一般例外条款以重新平衡外国投资者与东道国间权利义务关系。而目前中国已成为仅次于美国的第二大引资国,对外投资也上升至世界第三位。兼具东道国与投资者母国的双重角色使得中国更加关注如何在未来缔结的国际投资协定中既能够捍卫东道国的经济主权又能够保护日益活跃的海外投资。2012 年中国在与加拿大所缔结的双边投资协定中首次纳入了一般例外条款,尽管该协定尚未生效,但这一尝试仍然引发各界关注,意味着中国开始在国际投资协定谈判中以更加具体的方式、更加积极的姿态关注可持续发展目标。

本文将探讨国际投资协定是否有必要增设一般例外条款,如 GATT 第 20 条或 GATS 第 14 条,允许东道国为实现保护如人类、动植物生命或健康等目标而豁免投资保护义务。确保国际投资协定与国家公共政策之间的一致性。当然,一般例外条款的功能实现将取决于两方面因素,第一,国家公共政策的目的与实施方式应当满足特定要求,包括非歧视、不专断、正当程序及透明度。第二,即使满足前一条件,一般例外条款功能实现仍有赖于条约解释,即仲裁庭是否为国家公共政策行使余留更多空间,不片面追求投资自由化,重建投资者——东道国权利义务关系的平衡。

一、国际投资协定一般例外条款的现状

研究发现,至少 200 项国际投资协定中订入了例外条款,这些例外条款大多与具体义务有关,如国民待遇例外,国家根本安全例外,公共秩序、审慎措施或税收。③ 2012 年新签订的 30 项国际投资协定中,就有 17

* 本文受 2011 年教育部人文社会科学研究一般项目青年基金(项目编号:11YJC820064)、中山大学人文社科青年基金项目(项目编号:12000 - 3171913)的资助。

** 中山大学法学院副教授,法学博士。

① See UNCTAD: World Investment Report 2013. http: //www. unctad. org.

② See UNCTAD: World Investment Report 2013. http: //www. unctad. org.

③ See Marie - Claire Cordonier Segger, Markus W. Gehring & Andrew Newcombe, Sustainable Development in World Investment Law, Wolters Kluwer Law & Business, Nov. 1, 2010, p. 358.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项国际投资协定以不同形式体现了对可持续发展目标的关注,其中有 10 项协定明确规定了一般例外条款。④

加拿大是经合组织(OECD) 成员中唯一在投资协定范本中订入一般例外条款的国家,其 2003 年《外国投资协定范本》(Foreign Investment Protection Agreement,FIPA) 中包含与 GATT 第 20 条类似的一般例外条款,并体现在其缔约实践中,如 2007 年《加拿大 - 秘鲁双边投资协定》第 10 条规定,这些措施的实施不得在投资或投资者间构成恣意或不合理的歧视,或构成对国际贸易或投资的变相限制。本条约中的任何条款不应被解释为阻止缔约方采取或执行下列必要措施: (1) 为了保护人类,动物或植物的生命或健康; (2) 为了确保符合不与本条约条款冲突的法律、规章的规定; 或者(3) 为了保护可用竭的生物或非生物自然资源。

此外,2004 年《约旦 - 新加坡双边投资协定》,拉脱维亚《投资协定范本》中均订入了一般例外条款。⑤ 而在亚洲国家签订的自由贸易协定中也出现了类似 GATT 第 20 条的一般例外条款,如《新加坡 - 约旦新时代经济伙伴协定》第 83 条,2008 年《中国 - 新西兰自由贸易协定》第 200 条,2009 年《东盟全面投资条约》第 17 条,2012 年《中国 - 加拿大投资保护协定》第 33 条。尽管这些条约中的一般例外条款措辞不尽相同,但均与 GATT 第 20 条相似,既强调国家措施是为了实现若干目的所必需,也强调措施实施的方式不得造成恣意或不合理的歧视,或构成对国际贸易、投资的变相限制。

值得注意的是,2013 年《欧盟与加拿大全面经济贸易协定》投资规则草案中也纳入了一般例外条款,涵盖了以保护人类、动植物生命或健康; 确保遵守国内法; 以及保护有生命或无生命的可用竭的自然资源为目的的必要措施。而欧盟还希望进一步扩大一般例外条款的范围,力争把保护公共安全、公共道德和公共秩序,以及保护艺术、历史和古迹等国家财富所必要的措施也一并纳入一般例外条款。欧盟与加拿大已就该条款的适用应借鉴 WTO 一般例外条款"必要性"审查达成一致。⑥ 尽管各方就一般例外条款是否能确保主权国家必要的政策空间仍然存在争议,但显然欧盟与加拿大均希望通过一般例外条款确保东道国在一些敏感领域采取规制性措施的权力。

二、WTO 专家组与国际投资仲裁庭关于一般例外条款司法经验的比较

(一) WTO 协定与国际投资协定所面临的共同难题

国际投资协定一般例外条款常采用与 GATT 第 20 条相似的措辞,而 WTO 争端解决专家组在 GATT 第 20 条的解释和适用方面积累了丰富经验,包括,第一,援用例外的国家一方承担举证责任,证明所采取措施符合例外条款规定; 第二,对例外条款实行双重(two - tiered) 审查。即该措施是否符合例外清单一项或数项之具体规定; 以及该措施是否符合序言之要求。⑦ 而第一层次的审查又分解为两步,一是措施是否符合例外条款规定的目的,二是措施是否为实现该目的所"必需"(necessary) 。第三,"必需"定位为实现合法目的所必不可少(indispensable) ,或者该措施具有唯一性。专家组主要考虑的因素包括了该措施所保护的公共利益或价值的相对重要性; 该措施就实现该目标的实际效果; 该措施对自由贸易的限制程度和影响。第四,一般例外序言部分则彰显了善意原则和禁止权利滥用。在缔约方援用例外的权利和尊重其他缔约方的条约权利间保持平衡。

GATT 第 20 条是有限制、附条件的例外条款,WTO 争端解决专家组及上诉机构在分析措施的"必要性"时采取了利益比较与平衡法。而国际投资争端仲裁庭在适用国际投资协定例外条款时也总是要考量东道国援引例外的权利与遵守投资保护义务间的复杂关系。基于二者均面对贸易投资自由化与公共利益保护潜在冲突的共同难题,国际投资仲裁庭在实践中总是非常自然地借鉴 WTO 专家组关于一般例外条款的司法经验。

---

④ See UNCTAD: World Investment Report 2013. http: //www. unctad. org.

⑤ See OECD, International Investment Agreements: A Survey of Environment, Labour and Anti - corruption Issues, International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations, Paris: OECD, 2008, p. 181.

⑥ See Nathalie Bernasconi - Osterwalder, The Draft Investment Chapter of the Canada - EU Comprehensive Economic and Trade Agreement: A Step Backwards for the EU and Canada? http: //www. iisd. org.

⑦ 参见黄志雄《WTO 自由贸易与公共道德第一案——安提瓜诉美国网络赌博服务争端评析》,载《法学评论》2006 年第 2 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从已决案件来看，投资仲裁庭较为青睐 WTO 专家组对一般例外条款所持的严格解释的态度，倾向于强调国际投资协定保护、促进投资的宗旨，在多起案件中，仲裁庭认为双边投资协定序言表明缔约方缔约目的明确，即承诺为进入己方领土的私人投资者创造有利条件，并予以有效保护，提高投资积极性，⑧仲裁庭对相关条款的解释应当有利于受保护的投资。从严解释的倾向导致东道国较难成功援用投资协定例外条款作为抗辩依据，例如在 Canfor v. USA 案，Terminal Forest v. USA 案，Enron v. Argentine 等涉及例外条款适用的案件中，仲裁庭认为，即便在经济危机时期，确保投资协定保护、促进投资的目的之实现仍是东道国的条约义务，任何使东道国免除该义务的条约解释都难以与前述目的相符，因此，从严解释是仲裁庭的不二之选。

不过，Saluka v. Czech 案仲裁庭的观点却与众不同，它指出保护外资并非国际投资协定的唯一目的，如果对国际投资协定条款的解释过分夸大了保护外国投资的目的，反而会令东道国对外资望而生畏，不利于上述目的的实现。因此，需以平衡各方利益的方法解释条约。⑨ 无独有偶，Plama v. Bulgaria 案仲裁庭亦认为以“唯目的论”方法解释条约在极端的情形下甚至会否定缔约方的真实意图。⑩

（二）国际投资仲裁庭应形成有别于 WTO 专家组的司法经验

非歧视原则是 WTO 体制的重要基础，而东道国以公共利益保护为目的的规制措施也时常被投资者提起违反待遇之诉，包括违反投资协定下的国民待遇、最惠国待遇和公平公正待遇。仲裁庭对投资待遇条款的解释与东道国公共政策实施权限密切相关，审查重点在于政府措施是否遵循了非歧视原则，包括衡量“相似情形”（like circumstances）、“较少限制选择”（less - restrictive alternative）、“较低待遇”（less favorable treatment）等要素。

政府措施一旦被打上“歧视”的烙印，即便该措施宣称旨在保护公共利益，东道国也难逃违反投资待遇的厄运。通常，政府措施是各方竞争利益妥协与平衡的结果，其目的往往并不单一，要认定和证明其真正目的实非易事。而经济增长与可持续发展问题往往相互依存、相互促进，这也决定了一项政府措施目的的多重性。而在一些情况下，经济发展与公共利益的对立可能非常突出，一旦有证据证明公共利益受到严重威胁，该措施保护公共利益的目的应当受到优先考虑，如保护公共健康、安全与环境。

如果以保护公共利益为目的的政府措施遵守正当程序，并有科学依据，仲裁庭一般也会对东道国主权予以尊重，而由投资者举证该措施导致了不正当的歧视，或证明受到了变相保护主义的伤害、以及政府宣称要保护的公共利益并未受到威胁或伤害，政府措施只是为了实现贸易保护主义。

尽管 WTO 协定与国际投资协定同样规定了非歧视原则，但不能忽视两套体制的缔约基础、缔约目的，所服务的经济部门（货物贸易、服务贸易、技术贸易与投资）有联系但是更有区别，贸然把 WTO 争端解决的法律逻辑照搬到国际投资仲裁中，就是无视以下差异：

1. 国际投资协定体制缺乏对规制性措施的协调一致。例如 WTO《动植物检疫检验措施协定》（SPS）认可主权国家通过检疫措施维护国内公共健康与安全的权力，但考虑到对外国产品市场准入的影响，以及对出口国产品出口成本的增加，为了促进自由贸易而设定了协调一致的国际标准。而外国投资者及其投资面对的是形态各异的东道国管制措施，国际投资协定短期内也不可能在发展水平、法律传统各不相同的国家间就投资管制措施达成协调一致的国际标准。⑪

2. 必要性审查。在是否要求东道国选择对贸易较少限制的措施（less - trade restrictive alternatives）方面，国际投资协定与 WTO 协定也不尽相同。根据国家经济主权原则，一国有权自主决定对公共健康、安全、

⑧ E. g., Siemens v. Argentine, ICSID Case No. ARB/02/8, Decision on Jurisdiction, 3 Aug. 2004, para. 81; SGS v. Philippines, ICSID Case No. ARB/02/6, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 29 Jan. 2004, para. 116.

⑨ See Saluka Investment BV. v. Czech, UNCITRAL, Partial Award, 17 Mar. 2006, para. 300.

⑩ See Plama Consortium Limited v. Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on Jurisdiction, 8 Feb. 2005, para. 193.

⑪ See Marcos Orellana, Investment Agreements & Sustainable Development: the Non - Discrimination Standards, Sustainable Development Law & Policy 11, No. 3, 2011. http://www.wcl.american.edu/org/sustainabledevelopment.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

环境保护的水平。[12] 其次,并非所有国际投资协定一般例外条款均规定采取措施的国家有义务证明措施的必要性,而 GATT 第 20 条却明确规定了措施的"必要性"要求,其审查应考虑是否存在可获得同样保护效果的、更加合理的可替代措施,包括相似的管理成本,但实质性较少对自由贸易的限制效果。在缺乏条约明确规定的前提下,国际投资协定中的非歧视原则并不必然包括"必要性"审查。

3. "相同情形"是判断是否构成歧视的关键因素,在投资待遇之诉中,"相同情形"往往指在同一经济部门内从事相同的经营活动、具有竞争关系的投资者及其投资。不过,这仍然是一个有弹性的概念。美国贸易代表在《多边投资协定》(MAI) 谈判中曾指出,即便是完全符合最惠国待遇和国民待遇的措施在特定情形下也可能形成差别待遇。例如投资位于湿地的外国投资者根据环境保护法律可能受到区别于其他内国或外国投资者的待遇,这取决于投资的地理位置而不是投资者国籍。因此确有必要明确何谓"相同情形",以避免环境措施仅仅因为差别待遇而受到投资者挑战。[13]

S. D. Myers v. Canada 案仲裁庭认为衡量是否"相同情形",应当考虑为了保护公共利益而产生差别待遇的政府措施的具体情况,尽量使其合法化。[14] 国际投资仲裁庭在比较特定经济因素的同时还要考虑非歧视原则应当包含合理例外,即容忍为了合法的公共政策目的而导致的差别待遇。不过实践中,这一合理例外很可能成为国际投资保护和自由化的牺牲品,东道国以此作为抗辩理由,成功与否还有赖于国际仲裁庭对条约的解释,以及利益天平的倾向。

比较棘手的问题是如果公共政策措施所产生的差别待遇是以国别为基础,特别是东道国为了实施多边环境协定而违反国际投资协定待遇条款,如多边环境协定为了合理的环境技术转移目的对外国投资者施加履行要求措施。如《京都议定书》(Kyoto Protocol) 清洁发展机制(Clean Development Mechanism)[15]允许国家对来自经济发达水平不同国家的投资者给予差别待遇。在此情况下,"相同情况"就应当考虑多边环境协定的规定,即公共政策措施是基于多边环境协定的要求。

4. 救济方式不同。国际投资仲裁庭无权干预缔约方国内法的修改。例如根据 NAFTA 第 1135 条,仲裁庭仅有权裁决要求败诉缔约方给予金钱损害赔偿,包括恢复原状。而 WTO 争端解决机构则有权要求败诉方修改与条约义务不相符合的国内法措施。如败诉方拒绝,争端双方必须就双方均接受的补偿进行磋商,磋商无果,胜诉方有权对败诉方采取贸易制裁措施。

综上所述,把 WTO 体制下对政府措施的审查照搬到国际投资协定领域显然过于轻率,而以"对贸易较少限制的选择"作为衡量政府措施是否构成歧视的标准,在国际投资仲裁中并不必然具有决定性意义。国际投资仲裁庭在进行措施必要性审查时,也必须考虑到上述贸易体制与投资体制的本质差别,否则有可能造成仲裁庭的越权,同时令东道国保护公共利益的正当权力受到过分干预。

三、从规制性征收之诉的演进看一般例外条款的必要性

近年来规制性征收之诉的发展,较为典型地反映了投资保护与环境措施间的矛盾,也凸显了一般例外条款在国际投资协定中日益重要的地位。以目前投资争端解决最为活跃的 NAFTA 为例,[16]作为较早在投资章中纳入环境措施的条约,NAFTA 第 1114 条"环境措施"规定,本章中的任何规定都不得被解释为妨碍缔约方采取、维持或者执行任何环境保护措施。该条款旨在维护缔约方环境规制权。但在实践中,该条款在确保东道国公共政策权力空间的作用极为有限,远不及 GATT 第 20 条一般例外条款在协调自由贸易与公共利益冲

---

⑫ See Kojo Yelpaala, Fundamentalism in Public Health and Safety in Bilateral Investment Treaties (Part Ⅱ), 3 Asian J. WTO & Int' Health L. & Pol' yw, 2008, pp. 465 – 466, 475 – 479, 492 – 493.

⑬ See John Wickham, Toward a Green Multilateral Investment Framework: NAFTA and the Search for Models, 12 Geo. Int' L Envtl. L. Rev. 2000, pp. 617, 631.

⑭ See S. D. Myers v. Canada, UNCITRAL, Final Partial Award (Nov. 13, 2000), 250, http://www.naftaclaims.com.

⑮ 联合国《京都议定书》清洁发展机制允许发达国家到发展中国家购买经核证的减排量用来完成自己的减排任务,使发达国家能够以较低成本履行减排义务,发展中国家则能够借此从发达国家获得资金和技术并促进本国的可持续发展,企业则可以通过出售减排量获得额外收益。

⑯ 截止 2012 年 11 月,NAFTA 第 11 章下共有投资者 – 国家争端 61 起,其中以加拿大为被告的案件 26 起,以美国为被告的案件 19 起,以墨西哥为被告的案件 16 起。参见 http://www.naftaclaims.com。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

突方面发挥的重要作用。

征收条款作为投资协定实体规则中最为重要的内容，源自保护外国人及其财产的国际习惯法。进入 20 世纪 90 年代，征收之诉表现形式多样，东道国因直接征收被诉的案件并不常见，而以干涉外国人财产权或影响其权益实现的间接征收、渐进式征收、变相征收已成为外国投资者索赔的主要诉因。[17] 国际仲裁庭在此类案件的裁决中则反映出不同的利益倾向。

1. Metalclad v. Mexico 案: 投资者利益倾向

Metalclad 案作为首起 NAFTA 投资争端，墨西哥因其环境措施最终败诉，点燃了公众对 NAFTA 不惜以牺牲公共利益促进投资自由、投资保护的广泛质疑，而此后以加拿大为被告的 Ethyl 案、Pope & Talbot 案及 S. D. Myers 案均因东道国环境措施而起，更是引发了包括全世界范围内对东道国公共政策空间受到过分挤压的深刻忧虑。

墨西哥在 Metalclad 案中主张，解释公平公正待遇(NAFTA 第 1105 条) 及征收条款(NAFTA 第 1110 条) 应当根据条约上下文进行，包括环境条款(NAFTA 第 1114 条) 、NAFTA 前言以及《北美环境合作协定》(North American Agreement on Environmental Cooperation) 。[18] 即便不考虑墨西哥缔结的其他环境条约，NAFTA 本身也规定了东道国在承担投资保护义务的同时应考虑环境问题。仲裁庭接受了上述观点，把审查重点转向墨西哥行政许可程序是否满足透明度要求。仲裁庭认为无需考虑政府生态保护令的目的或动机，甚至生态保护令本身对认定征收无实质影响，而是其实施的效果构成了类似征收的行为，即采纳了纯粹“效果原则”。[19] Metalclad 案仲裁庭引入“经济性剥夺原则”扩张了规制性征收的定义，引发了社会公众的广泛质疑和焦虑，该扩张解释足以令善意的政府管理措施举步维艰。该案裁决最终被加拿大不列颠高等法院部分撤销，其间 Tysoe 法官毫无掩饰地批评了仲裁庭对间接征收的恣意扩张解释。[20]

而在 Santa Elena v. Costa Rica 案[21]中，东道国因保护国家公园周围环境的规制措施被外国投资者指控构成征收，仲裁庭认为，涉案措施并不因环保目的而改变其剥夺投资者财产的本质。即便该措施受到公众欢迎并有益于公众，也不影响该措施如同其他征收措施一样，应给予外国投资者赔偿。在 Tecmed v. Mexico 案中，仲裁庭甚至拒绝审查墨西哥政府措施的目的，哪怕墨西哥政府正是出于环境与公共健康考虑而不再给予西班牙投资者 Tecmed 公司垃圾掩埋场许可证。[22]

仲裁庭在上述案件中完全倒向私人投资者的利益，无视东道国保护公共利益措施的正当性而受到了广泛批评与舆论压力。当然也有人提出媒体、环保组织甚嚣尘上的担忧有其夸张的一面，败诉的结局反而促进了墨西哥废物处理管理体系的完善，催生了更为有效的法律。[23] 但此种说辞也无法掩盖在上述案件中仲裁庭漠视东道国公共利益的事实。

2. Methanex v. USA 案: 公共利益倾向

在以 Methanex v. USA 案为代表的，存在私人利益与公共利益之争的投资争端案件中，仲裁庭则表现出对公共利益的额外关注。纯粹的效果原则在 Methanex 案中被仲裁庭抛弃，转而适用“效果目的原则”，指出蓄意歧视是构成征收的关键因素。根据一般国际法，为了公共目的，符合正当程序，非歧视并给予补偿的政

---

[17] See C. Yannace - Small, “Indirect Expropriation” and the “Right to Regulate” in International Investment Law, OECD Working Papers on International Investment (Sep. 2004) , http: //www. oecd. org/dataoecd/22/54/33776546. pdf. ; Andrew Newcombe, The Boundaries of Regulatory Expropriation in Protection and Regulatory Taking in International Law, 50 ICLQ (2001) : 811, http: //papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm? abstract_id = 703244.

[18] See Metalclad Corp. v. United Mexican States, Mexico's Counter - memorial, 17 Feb. 1998, para. 838.

[19] 最早由 Rudolf Dolzer 教授提出依“纯粹效果”来衡量政府措施的经济影响，并判断是否构成间接征收。See Rudolf Dolzer, Indirect Expropriation: New Developments, 11 NYU Environment Law Journal, 2002, p. 79.

[20] See The United Mexican States v. Metalclad Corporation, 2001 BCSC 664.

[21] See Compañia del Desarollo de Santa Elena S. A. v. Republic of Costa Rica, ICSID Case No. ARB/96/1.

[22] See Técnicas Medioambientales Tecmed, S. A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF) /00/2.

[23] See S. Gaines, Environmental Policy Implications of Investor - State Arbitration under NAFTA Chapter 11, http: //www. cec. org/Storage/58/5068_Final - Gaines - T - E - Symposium05 - Paper_en. pdf, at 14.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

府措施将不构成征收,除非政府曾承诺不实施该项措施。[24] Methanex 案仲裁庭进一步分析,加州政府的措施无需赔偿因其本身并非征收措施,东道国政府承担投资保护义务的同时应保留必要的政策空间,而外国投资者对此应当有合理预期。但仲裁庭的推理仍然令人困惑,如果 Methanex 案中美国政府的规制措施不构成征收,那何种规则性措施将导致索赔,而何种规制性措施虽无补偿却仍然合法,仲裁庭对此并无清晰解释。

在 Chemtura v. Canada 案中,仲裁庭坚决维护了加拿大政府禁用杀虫剂林丹的管制措施。对于 NAFTA 第 1110 条征收条款,如同直接适用 2004 年美国 BIT 范本附录 B 征收例外[25]——将环境规制措施排除在间接征收之外,而这一规定被视为对 NAFTA 前十年(1994 – 2004)征收之诉所引发的混乱与质疑的终结,且为此后国际投资征收之诉确定了基调,安抚国际社会对投资规则侵蚀缔约国公共管理权的担忧。

更有趣的是 2011 年 5 月 Dow Chemicals v. Canada 禁用除草剂(2,4 – D)案达成和解,[26]陶氏化学撤回起诉,并放弃未来就该案的一切法律救济。而魁北克政府既无需撤销禁令亦无需给予赔偿。不过原被告发布联合声明,2,4 – D 对人类健康或环境并无显著危害;加拿大地方政府今后可能采取更加严格的除草剂控制措施,针对包括原来已取得政府认证的除草剂。这为今后加拿大政府实行更加严格的环境保护措施埋下了伏笔。

3. 比例原则的应用: 重建投资者与公共利益的平衡

与上述存在明显利益倾向的案件不同,在一些案件中仲裁庭则表现出对投资者与公共利益平衡的追求,既对国家主权予以充分维护,将东道国保护公共利益的合法措施排除在征收之外,也兼顾外国投资者利益,要求规制措施符合正当程序的要求。仲裁庭适用了“比例原则”判断政府措施是否构成征收。在 Tecmed 案与 Azurix 案中,仲裁庭均提及,以维护公共利益为目的而剥夺投资者财产的政府措施,其实施方式对于所追求的目标应当合乎比例。[27] 此外,还应考虑投资者对该措施决策过程的参与程度,措施对投资的实质影响。[28]而被告东道国一方须对涉案措施关乎重大公共利益(some genuine interest of public)承担举证责任。

在涉及环保、公共健康与安全的投资案件中,焦点多集中于政府规制措施的科学基础。主张索赔的投资者通常举证政府措施缺乏科学依据或错误,因而是武断的,构成对国内公司或产业的变相保护。而被告东道国的抗辩则力证政府决策过程有合理的科学依据。仲裁庭屡屡左右为难,有学者建议,仲裁庭应当把审查重点放在政府决策过程是否有科学依据,客观性以及符合正当程序,而不在于科学依据本身的正确性。[29]

仲裁庭过分纠结于科学依据的正确性对利益平衡的实现无所助益,毕竟仲裁员不是科学家。从利益平衡的角度考虑,仲裁庭应重点审查以下因素: 政府决策过程是否以国际法和国内法为依据,满足透明度、非歧视原则以及以科学依据为基础等客观标准和正当程序要求。

当然,国际仲裁庭并不遵循先例,上述分析也不过基于对已决案件仲裁庭裁决作出的大致分类,并不代表未来仲裁庭必然会延续其中哪一种倾向去面对私人投资者利益与公共利益之争。规制性征收之诉的演进催生了征收条款例外成为国际投资协定中的必备条款,同时也足以推动缔约国更加重视国际投资协定一般例外条款的作用,至少这些条款可以从某种程度上有利于重建投资者利益与公共利益间的平衡。

四、结语

国际投资协定一般例外条款的价值主要在于确保东道国公共政策空间,并允许国家在特定情况下降低投资保护水平。附清单的一般例外条款把这些特定情况成文化,为仲裁庭裁判提供明确指引,以确保东道国

---

[24] See Methanex v. the United States of America, Final Award, Part IV, Chapter D, para. 7.

[25] 2004 年美国 BIT 范本附录 B “是否构成间接征收,应基于事实逐案认定,并考虑以下因素: 政府行为的经济影响,对(外国投资者)合理期待干预的程度,政府行为的性质。除罕见情况外,缔约一方出于保护合法的公共福利目的,如公共健康、安全和环境等采取的非歧视规制措施,不构成间接征收。”这一规定在 2012 年美国 BIT 范本中得以沿用。

[26] See Dow AgroSciences LLC v. Canada, notice of arbitration, 31 March 2009. Settlement Agreement, 25 May 2011 http://www.international.gc.ca/trade – agreements – acords – commerciaux/disp – diff/agrosciences archive.aspx? lang = en&view = d.

[27] See Azurix Corp. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12.

[28] See Tecmed, Award of Tribunal (May 29,2003), p. 46, paras. 121 – 22.

[29] See Shalisha Samuel, Dominic Davis, Shanika Roberts, Environmental Regulation and Investor Expectations under NAFTA, http://dspace.cigilibrary.org/jspui/handle/123456789/27852.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对公共事务的规制权力，促使仲裁庭在条约解释时考虑到东道国投资保护义务与公共政策目标间的适当平衡。不过，亦有学者指出，仲裁庭从严解释的倾向易使该条款形同虚设，甚至可能起到反作用——限制东道国公共政策自由裁量权，倒不如放弃设置一般例外条款。[30] 从国际投资仲裁实践来看，这种担心也不无道理。特别是现行大多数国际投资条约例外条款较为抽象，没有如 GATT 第 20 条的“例外清单”时，仲裁庭的审查会更加灵活，投资条约一般例外条款能为东道国提供多少公共政策空间难以估计。

但是从征收条款的演进过程来看，征收例外条款从无到有，表明投资保护不应以牺牲环保、公共健康等重大利益为代价，仲裁庭也在征收之诉中从投资者利益倾向转向重建投资者利益与公共利益间的平衡，甚至对 Methanex 公司滥用诉权开出了近 300 万美元的“罚单”，偿付美国政府因应诉所产生的法律费用。因此，为了确保仲裁庭在适用其他投资保护实体条款时同时考虑到缔约国正当的公共政策空间，一般例外条款的作用不容小觑，国际投资条约保护与促进投资的宗旨不应与环境保护、公共健康等人类共同福祉相分离。

从缔约国的角度而言，一般例外条款并非万全之策，相应地，其以公共利益保护为目的的措施应当满足非歧视原则、符合正当程序、以科学依据为基础以及透明度要求，并兼顾措施的适当性，否则最终仍然可能要对利益受损的外国投资者承担赔偿责任。一般例外条款在国际投资条约中的出现对东道国的执政能力带来了新的挑战。

（责任编辑：黄德明）

[30] See Aaron Cosbey, The Road to Hell? Investor Protections in NAFTA's Chapter 11, in L. Zarsky (ed.), International Investment for Sustainable Development: Balancing Rights and Rewards, London: Sterling, VA: Earthscan, 2005.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net